

1501561-54.2020.8.26.0302
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso
Comarca: Jaú
Foro: Foro de Jaú
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/02/2022
... de Justiça de São Paulo:

"TÓXICOS - TRÁFICO - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaú
Foro de Jaú
2ª Vara Criminal
Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501561-54.2020.8.26.0302
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2216093/2020 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 13332601 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 3609/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2216093 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2216093 - DISE- DEL.SEC.JAÚ, 3609/20/406 - DISE- DEL.SEC.JAÚ
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GUSTAVO HENRIQUE MARTINS DE SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

GUILHERME RODRIGUES DA SILVA e GUSTAVO HENRIQUE MARTINS DE SOUZA estão sendo processados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Notificados às fls. 330 (Gustavo) e 395 (Guilherme), os réus apresentaram resposta às fls. 204/212 (Gustavo) e 399/401 (Guilherme).

A denúncia foi recebida em 20 de outubro de 2021 (fls. 403/404) e os réus foram citados às fls. 445 (Gustavo) e 447 (Guilherme).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e os réus foram interrogados

(fls. 451).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados (fls. 457/460).

As defesas postularam a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o artigo 28 da Lei 11.343/06 e a aplicação do benefício previsto no artigo 33, §4º, do mesmo diploma legal (fls. 468/477 e 484/491).

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 3/4 e 5/6), boletim de ocorrência (fls. 13/16), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), fotografias (fls. 31/34 e 66/83) e laudos periciais (fls. 135/139 e 213/303), além da prova oral.

A autoria é certa.

Em juízo, o réu Gustavo rechaçou a acusação e disse que trazia consigo apenas cinco porções de maconha, que forneceria para Guilherme e fumariam juntos. Negou que tivesse se levantado ao avistar a viatura e disse que um dos policiais trouxe consigo uma meia com algumas porções de maconha para incriminá-los falsamente. Os policiais ainda estiveram em sua residência, mas nada encontraram. Disse que havia cinco pessoas no local e que já foi abordado anteriormente pelos policiais ouvidos. Executava serviços esporádicos como servente de pedreiro na época dos fatos.

O réu Guilherme negou os fatos e contou que estava fumando maconha no local quando os policiais chegaram. Jogou fora o baseado que estava fumando e, durante a revista, nada de ilegal foi encontrado com nenhum dos integrantes do grupo. Durante busca nas proximidades, os policiais disseram que encontraram a droga apreendida. Possuía menos de R\$40,00 no momento da prisão, que seria destinado ao pagamento de uma pizza que havia encomendado. Não conhecia os policiais anteriormente. Realizava trabalhos esporádicos junto com seu primo.

Diogo, policial militar, relatou em juízo que estava em patrulhamento de rotina quando avistou dois indivíduos, que tentaram se dispersar ao visualizarem a viatura, motivando a abordagem. Durante revista, encontrou maconha (dividida em pequenas porções) dentro de uma meia que estava no bolso da blusa de Guilherme e dentro da cueca de Gustavo, além de dinheiro com cada um. Havia um menor de idade junto com eles, que não portava nada de ilícito e foi liberado. Nenhum dos acusados levava apetrechos que indicassem que a droga seria consumida no local. Guilherme alegou que estava passando por dificuldades financeiras e, por isso, decidiu comercializar drogas para colaborar com a família. Os acusados já foram abordados anteriormente no mesmo local e nunca viu ninguém fazendo uso de drogas ali.

Marcio, policial militar, confirmou a narrativa de seu colega de farda e acrescentou que, já na delegacia, Gustavo forneceu três endereços diferentes.

Conforme se vê, a negativa dos acusados foi rechaçada pelas provas colhidas.

Gustavo admitiu, sob o crivo do contraditório, que tinha cinco porções de maconha no momento da abordagem e que partilharia tal droga com o amigo. Guilherme, por sua vez, disse que ninguém estava com droga, malgrado tenha sustentado que estava fumando um baseado quando os policiais chegaram.

As contradições que permeiam as versões dos acusados enfraquecem sua negativa.

Noutra ponta, os policiais militares apresentaram narrativas harmônicas a respeito das circunstâncias que motivaram a abordagem, do encontro dos entorpecentes no bolso e na cueca dos réus, além da confissão informal de Guilherme.

E não há qualquer elemento capaz de afastar as sobreditas versões, até porque Guilherme informou que sequer os conhecia, enquanto Gustavo apenas mencionou já ter sido abordado por eles em outra oportunidade.

No mais, além das circunstâncias que motivaram a abordagem e da razoável quantidade de entorpecente já fracionada, eles também tinham dinheiro, sem comprovação de origem lícita.

A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 – 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator Willian Campos – julgado em 27 de maio de 2014 – votação unânime).

O fato de os réus não terem sido surpreendidos no exato momento da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do artigo 33 da Lei 11.343/06, que, como cediço, elenca diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal.

Nesta senda, decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

“TÓXICOS – TRÁFICO – Consumo – Prática de algum ato de tráfico ou “traditio” - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente – Suficiência”(....)” (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. “TÓXICOS – Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (....)”(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739.

Verifica-se, portanto, conjunto probatório harmônico em desfavor dos acusados, que não trouxeram elementos a infirmá-lo. E, ainda que eles sejam usuários, tal fato não acarreta a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio, já que uma conduta não exclui a outra e frequentemente coexistem.

Sobre o tema, veja-se:

“TOXICO – Tráfico – Absolvição – Inadmissibilidade – Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio – Prova colhida que direciona-se nesse sentido – Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância – Condenação mantida – Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 – Ribeirão Preto – 4ª Câmara Criminal – Relator: Bittencourt Rodrigues – 22.08.00 – v.u.).”

Nesta toada, não há como acolher as teses defensivas, pois o delito imputado aos réus restou suficientemente demonstrado.

Procedente a ação penal, passo a dosar as penas.

Na primeira fase, atentando ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, não observo circunstâncias aptas a ensejar a majoração da pena-base, ao que a mantenho no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na segunda fase, presente, para ambos, a agravante prevista no artigo 61, II, "j", CP, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo). Verifico, ainda, a atenuante da menoridade relativa (fls. 24 e 25), pelo que mantenho as penas no patamar anterior.

Aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à mingua de suficiente comprovação de que o acusado se dedicasse a atividade criminosa por tempo considerável antes dos fatos ou integrasse organização criminosa. Assim, diminuo a reprimenda em 2/3, tornando-a definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Considerando a primariedade dos réus, fixo, excepcionalmente, apesar do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, o regime inicial semiaberto para cumprimento das penas. É incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na lei mencionada, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado. O crime de tráfico de drogas, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos, notadamente patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem, de modo que a concessão dos benefícios mencionados, além de ser incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no artigo 44, III, CP.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

"O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo

juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea “b”, da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, “caput”, da CF)”(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim, por entender que o art. 387, §2º, CPP viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR os réus GUILHERME RODRIGUES DA SILVA e GUSTAVO HENRIQUE MARTINS DE SOUZA, qualificados nos autos, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Considerando a mesma pena e regime aplicados aos réus, a primariedade de ambos e o fato de que Gustavo responde ao processo em liberdade, faculto, excepcionalmente, o mesmo benefício em relação ao acusado Guilherme. Expeça-se, pois, alvará de soltura clausulado e comunique-se ao E. Tribunal de Justiça.

Determino o perdimento do objeto e do dinheiro apreendidos com os acusados, nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06.

Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. I. C.

Jaú, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA